

1501073-34.2021.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Mariana Teixeira Salviano da Rocha

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/01/2022

... do crime de associação para o tráfico de drogas, conforme passo a expor. É certo que, ordinariamente, nossa sistemática penal atual não tem exigido a reiteração criminosa do tráfico de drogas, ou delito de mesmo gênero, para a configuração da infração penal prevista no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06, pois o próprio teor deste dispositivo legal dispensa a persistência ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí/ Foro de Tatuí

1ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí - CEP 18278-440, Fone: (15) 3251-4013, Tatuí-SP - E-mail: tatui1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1501073-34.2021.8.26.0571

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2213545/2021 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 19487094 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 1789/21/609 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2213545 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Réu:

JONATAS PEREIRA DE SOUZA

Artigo da Denúncia:

Data da Audiência:

18/01/2022

Réu Preso

Em 18 de janeiro de 2022, às 13:30h, por meio da plataforma Microsoft Teams, onde virtualmente se encontrava a Exma. DR.^a MARIANA TEIXEIRA SALVIANO DA ROCHA, MM^a Juíza de Direito Titular, comigo Escrevente Técnico Judiciário ao final nomeado, pela MM^a Juíza foi determinado que se abrisse a presente teleaudiência, o que foi feito, com as formalidades legais. Apregoadas as partes, virtualmente se achavam: o representante do Ministério Público, na pessoa do DR. CARLOS EDUARDO POZZI, DD. Promotor de Justiça da Comarca de Tatuí, o réu JONATAS PEREIRA DE SOUZA, bem como o seu Defensor Técnico, DR. João Pedro de Oliveira Masson OAB 94899/RS. Ainda, encontravam-se na sala de reunião virtual as testemunhas Ana Lúcia Pereira de Souza, Tamires Lopes Cardoso e Heleno Molinari Lopes (PM). INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes na realização do ato de forma virtual, foi dada a oportunidade de o acusado se entrevistar reservadamente com o seu Defensor. Ato contínuo, o representante do Ministério Público disse que desistia da oitiva da testemunha José Vicente Candera Júnior (PM), bem como o defensor, que disse que desistia da oitiva da testemunha, Sra Márcia Regina Pereira, o que restou HOMOLOGADO pela MMA Juíza de Direito. Em seguida, foram ouvidas as testemunhas

acima mencionadas, passando-se ao interrogatório do réu. As perguntas foram inicialmente formuladas pela MMª Juíza de Direito, eis que as partes não solicitaram que as inquirições fossem por elas iniciadas. Em razão da suspensão dos trabalhos presenciais nos prédios do Tribunal de Justiça de São Paulo, como forma de prevenção e contenção do Covid-19 (Provimento nº 2545/2020 do Conselho Superior da Magistratura), a presente audiência foi realizada excepcionalmente por meio audiovisual, através da plataforma Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020, com o armazenamento dos arquivos digitais conforme determinado no Comunicado CG nº 1350/2020. Por fim, devido à instabilidade na rede de internet, cada oitiva será gravada em arquivo individual, identificados, para que não haja o risco de perda de a gravação, acaso toda a solenidade seja gravada em apenas um arquivo. Na sequência, pela MM. Juíza de Direito foi dito: Não havendo mais provas a serem produzidas ou colhidas, dou por encerrada a instrução e concedo a palavra às partes, para os debates. Os debates orais foram gravados em audiovisual, na forma acima mencionada. Ato contínuo, pela MM. Juíza de Direito foi proferida a seguinte SENTENÇA: "Vistos. O réu JONATAS PEREIRA DE SOUZA, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, e art. 35, caput, ambos c.c. art. 40, incisos III e VI, todos da Lei 11.343/06, eis que: 1) no dia 8 de agosto de 2021, nesta cidade e Comarca de Tatuí, se associou com o adolescente Kauan Gonçalves Floriano (16 anos de idade) para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de drogas; e 2) no dia 8 de agosto de 2021, na Rua Professor Mario Baiardi, nº 202, nesta cidade e Comarca de Tatuí, nas proximidades do "Pronto Socorro do Bairro São Cristóvão" e da "EMEI Yolanda de castro Del Fiol" (fls.102), previamente ajustado, agindo em concurso, com unidade de desígnios e identidade de propósitos com o adolescente Kauan Gonçalves Floriano (16 anos de idade), trazia consigo, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 28 porções de "crack", subproduto da cocaína, com peso bruto aproximado 7 gramas, e 66 porções de cocaína, com peso bruto aproximado 36 gramas,, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo consta da exordial, na data dos fatos, o acusado se dedicava ao tráfico ilícito de drogas de forma associada com adolescente. Na prática delitiva, JONATAS e Kuan permaneciam no local da abordagem, aguardando usuários para promover a venda oportuna, cada um deles portando algumas porções de cocaína, drogas que lhes pertenciam e estavam destinadas à mercancia ilícita. Policiais Militares estavam em serviço quando, ao ganharem a Rua Prof. Mario Baiardi, avistaram JONATAS e Kuan juntos na via pública. Ao perceberem a aproximação da viatura, o acusado e o adolescente dispensaram dois pacotes de drogas, atirando as drogas em direções diferentes, tentaram fugir numa bicicleta, no entanto, foram de pronto perseguidos e detidos pelos Policiais. Após efetuarem a abordagem, os policiais verificaram o conteúdo dos pacotes dispensados pelo denunciado e pelo adolescente e encontraram 28 pedras de "crack" dentro de uma sacola e 66 porções de cocaína no interior do outro pacote, individualmente embaladas e prontas para serem comercializadas. Durante as buscas, foi apreendido 1 aparelho de telefone celular. O réu foi notificado (fls. 128) e apresentou Defesa Preliminar (fls. 158/164). Assim, por decisão proferida no dia 03 de dezembro de 2021, foi recebida a denúncia (fls. 166/170). Durante a instrução, foram ouvidas cinco testemunhas, ultimando-se com o interrogatório do réu, tudo gravado em audiovisual. Em sede de alegações finais, o Órgão Ministerial postulou pela condenação do acusado nos exatos termos da Denúncia, enquanto a Defesa Técnica, de outro lado, pugnou pela absolvição do acusado, sustentando insuficiência probatória, bem como, subsidiariamente, a desclassificação delitiva e, finalmente, em caso de condenação, pela incidência de todas os benefícios legais cabíveis a incidir em dosimetria da pena e na fixação do regime prisional inicial. Folha de antecedentes a fls. 26/29, bem como Certidões a fls. 30/32 e 211/212. É o relatório do necessário. Fundamento e Decido. Pois bem, o pedido ministerial comporta parcial procedência, absolvendo-se o réu da imputação da prática do crime de associação para o tráfico de drogas, conforme passo a expor. É certo que, ordinariamente, nossa sistemática penal atual não tem exigido a reiteração criminosa do tráfico de drogas, ou delito de mesmo gênero, para a configuração da infração penal prevista no art. 35, caput, da Lei nº

11.343/06, pois o próprio teor deste dispositivo legal dispensa a persistência delitiva: "Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 10, e 34 desta Lei:" (grifos aditados). No entanto, para se que não se confunda o mero concurso de pessoas – de que trata o art. 29 do Código Penal – com o delito de associação, estabeleceu-se o entendimento jurisprudencial e doutrinário que, para a caracterização do crime em comento, é imperioso que o dolo dos agentes que agiram em conluio projete-se por mais de um fato criminoso, ou seja, que pretendam exercer a narcotraficância em caráter permanente, estável e duradouro, denotando vínculo associativo e não mero concurso eventual. Neste sentido, coleciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: "(...) 1. Para a caracterização do crime de associação para o tráfico é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não se subsume ao tipo do artigo 35 da Lei n.º 11.343/2006. Precedentes. (...)” (STJ - HC: 214660 SP 2011/0178723-1, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 14/05/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2013). Além disto, coleciono também o seguinte julgado do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: "(...) Associação para o tráfico - Absolvição - Admissibilidade - O artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, não pode ser considerado um mero concurso de agentes, sendo necessário, para sua caracterização, a existência de um vínculo associativo, em que a vontade de associar-se seja distinta da vontade da prática do crime visado (...)” (TJ-SP - APL: 00128516320108260344 SP 0012851-63.2010.8.26.0344, Relator: Borges Pereira, Data de Julgamento: 01/04/2014, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/04/2014). Em idêntica lógica, assevera Guilherme de Souza Nucci que: "(...) Exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico (...)” (Nucci, Guilherme de Souza, Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Volume 1, Editora Revista dos Tribunais, 7ª ed, p. 337, item 103). Assim, observando a premissa estabelecida e examinando o conjunto probatório amealhado nos autos, noto que, embora haja comprovação de que o acusado e o adolescente exerciam o tráfico de entorpecentes, inexistem provas suficientes de que praticavam ou pretendiam perpetrar a narcotraficância em caráter permanente. Isto porque não houve prévia investigação policial, onde fosse possível verificar que o tráfico não seria exercido pontualmente, tampouco foram localizados instrumentos de preparação ou anotações de contabilidade, revelando o caráter não episódico da traficância. Portanto, diante da ausência de provas em relação ao animus associativo entre o réu e o adolescente, imperiosa a absolvição deles no que se refere à imputação de ofensa ao art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. E mais, deve ser afastada a causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, pelas razões que passo a expor. A despeito da majorante em questão ter natureza objetiva e, portanto, dispensar a intenção do traficante de captar sua clientela junto aos frequentadores dos locais elencados no dispositivo legal supra citado, tem-se que, para não gerar responsabilidade penal objetiva, exige-se que haja concentração de pessoas nas proximidades e adjacências daquele lugar para justificar a incidência da causa de aumento especial em tela. Ora, a ratio da norma visa exasperar a pena de pessoa que se aproveita da aglomeração de pessoas nas proximidades daquele local, facilitando a ocultação e evasão do traficante. In casu, como os fatos se deram depois das 18h00, e o estabelecimento de ensino e a unidade de atendimento médico apontadas na denúncia tem horário de funcionamento até às 18h00. Estavam, portanto, fechadas quando dos fatos, não havendo concentração de pessoas a justificar a incidência da causa de aumento em questão. A propósito, assim se posiciona a jurisprudência do C. STJ: RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CAUSA DE AUMENTO DA PENA. ART. 40, INCISO III, DA LEI Nº 11.343/2006. INFRAÇÃO COMETIDA NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO EM UMA MADRUGADA DE DOMINGO. AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO DE UMA AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS À ATIVIDADE CRIMINOSA. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE. 1. A causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso

III, da Lei n.º 11.343/2006 tem natureza objetiva, não sendo necessária a efetiva comprovação de mercancia na respectiva entidade de ensino, ou mesmo de que o comércio visava a atingir os estudantes, sendo suficiente que a prática ilícita tenha ocorrido em locais próximos, ou seja, nas imediações do estabelecimento. A razão de ser da norma é punir de forma mais severa quem, por traficar nas dependências ou na proximidade de estabelecimento de ensino, tem maior proveito na difusão e no comércio de drogas em região de grande circulação de pessoas, expondo os frequentadores do local a um risco inerente à atividade criminosa da narcotraficância. 3. Na espécie, diante da prática do delito em dia e horário (domingo de madrugada) em que o estabelecimento de ensino não estava em funcionamento, de modo a facilitar a prática criminosa e a disseminação de drogas em área de maior aglomeração de pessoas, não há falar em incidência da majorante, pois ausente a ratio legis da norma em tela. 4. Recurso especial improvido. (REsp 1719792/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 26/03/2018). Quanto a proximidade de quadra poliesportiva noticiada pela testemunha Heleno Molinari, como não fora objeto da denúncia, deixo de considera-la para fins de recrudescimento da pena com base no artigo 40, inciso III da Lei 1134/06. No mais, a pretensão acusatória merece ser acolhida, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência de todas as elementares do delito de tráfico de entorpecentes, que se configurou consumado, não havendo dúvidas quanto à autoria, bem patenteada a tipicidade da conduta do crime descrito no artigo 33, caput, c.c. art. 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06. De fato, a materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), pelo boletim de ocorrência (fls. 03/05), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 06), pelo auto de constatação preliminar (fls. 07), pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 97/100) e, finalmente, pela contundente prova oral produzida. A autoria é igualmente evidente e clara. Vejamos: O réu, em solo policial (fls. 19), manteve-se silente. Em juízo, disse que no dia dos fatos dormiu na casa de sua mulher, foi para sua casa, passou o dia com seus familiares pois era festa da sua sobrinha. Combinou com Tamires de irem ao mercado e saiu de bicicleta. No trajeto os policiais o abordaram e disseram que ele havia jogado entorpecentes. Acontece que não jogou nada e não conhece o adolescente Kauan. Já foi preso pelo policial Molinari. Havia alguns indivíduos sendo abordados e não viu a droga no local – os policiais ficaram conversando atrás da viatura com umas pessoas e depois vieram os acusando porque ele já tem passagem. Nega que estivesse com qualquer droga. As perguntas da acusação – Tamires não estava no aniversário, iria busca-la para irem ao aniversário. Ela ligou para o telefone dele, este mesmo telefone que foi apreendido. Iriam ao mercado Spani Atacadista e se encontrariam na quadrinha. Nesta oportunidade o promotor de justiça com base no croqui de fls. 102 aponta que o supermercado era bastante longe do local de abordagem. Quanto as fotos de fls. 149 e ss., não foi ele quem tirou e sim os policiais que queriam incriminá-lo. As perguntas da defesa disse – já foi preso pelo polícia Molinari e foi absolvido nesse processo. Não tem carro e Tamires também não tem. Tem-se portanto que o réu ouvido sob o crivo do contraditório e ampla defesa negou por completo a prática delitiva, deduzindo sem lastro probatório que teria sido vítima de uma flagrante forjado. Ocorre que o réu foram encontrado dispensado substancia entorpecente e em companhia do adolescente Kauan, versão esta confirmado pelos policiais militares. Note-se que o depoimento das testemunhas de defesa não afasta a possibilidade de que o réu tenha se afastado do local em que se encontrava para vender os entorpecentes em companhia de seu comparsa. Bem observado ainda pelo Ministério Público que o supermercado apontando pelo réu, dista a grande distancia de onde fora abordado, sendo que tanto o réu como sua namorada que acompanharia não dispõe de veículo automotor. De outro lado, o Policial Militar José Vicente Canderá Junior, em sede policial (fls. 14), relatou que, na data dos fatos, juntamente com seu parceiro, estavam em patrulhamento de força tática pelo bairro, ao acessar a rua Professor Mario Baiardi próximo ao PS do bairro São Cristóvão e escola Yolanda de Castro Del Fiol, viu dois indivíduos, os quais, ao avistarem a viatura, jogaram algo em dois pontos diferentes e tentaram se evadir em uma bike. No entanto, logo foram abordados, verificando que eram o adolescente Kauan

Gonçalves Floriano e o acusado. Afirmou, também, que o objeto que eles tinham jogado foi localizado uma caixinha de plástico, contendo (28) pedra de crack e uma sacolinha contendo (66) micro tubos aparentando ser cocaína. Indagados, ambos negaram a propriedade da droga. Mas foi nítido quando vimos que os dois jogaram a droga e ainda tentaram se evadir. Em juízo por se encontrara de férias e para que não houvesse demora no andamento o feito, foi dispensada a oitiva pelo representante do Ministério Público. Convergindo em mesmo sentido, o também Policial Militar Heleno Molinari Lopes, em sede policial (fls. 15), corroborou integralmente a versão de seu colega de trabalho. Em juízo, as perguntas da acusação relatou que o bairro é conhecido pela incidência de trafico bem como réu e o adolescente já são conhecidos dos meios policiais. Ao se aproximarem do réu e do adolescente viram que ambos dispensaram algo ao chão, sendo que um dos invólucros dispensados tinha crack e o outro tinha cocaína. No quarteirão dos fatos há uma escola, um posto de saúde e um quadra que fica aberta dia e noite com crianças e adolescentes no local. As perguntas da defesa respondeu - essa quadra sempre fica aberta mas não se recorda se havia pessoas no local. Não se recorda se o bairro estava movimentado naquele horário. Em relação à validade e à eficácia probatória dos depoimentos dos agentes de segurança, impende destacar que nossos tribunais vêm rechaçando qualquer análise discriminatória quanto aos seus testemunhos, atribuindo-lhes valores idênticos às versões judiciais de demais testemunhas. Até mesmo porque, in casu, inexistem motivos para desqualificar os depoimentos dos policiais, pois não há provas ou indícios nos autos indicando que estes pretendiam incriminar injustamente o réu ou faltar com a verdade. Por tais razões, seus testemunhos merecem normal credibilidade e valor probatório. Neste sentido: Furto Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes dos guardas municipais, da testemunha e na confissão policial e judicial do réu Validade Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, principalmente se o acusado, ao ser interrogado perante a autoridade policial e em Juízo, tudo admitiu, Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos agentes públicos, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de agente público não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. (TJ-SP - APL: 00038815620128260198 SP 0003881-56.2012.8.26.0198, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 20/03/2014, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/03/2014) (grifos aditados). De outro lado, a testemunha Ana Lucia Pereira de Souza, em juízo, é irmã do réu e foi ouvida se compromisso. Disse que no dia dos fatos ocorria uma festa em sua casa e ele permaneceu no local. Ele estava na casa da Tamires e foi para sua casa depois do almoço. Depois eles combinaram de ir ao mercado e ao sair para ir ao mercado foi abordado e preso. Finalmente, a testemunha Tamires Lopes Cardoso, em juízo, disse que é namorada do réu e foi ouvido sem compromisso. Combinou de ir ao mercado com o réu e por volta das 18 horas ligou para o réu que estava em sua casa e iria encontra-la. Saiu para encontra-lo e viu que o réu foi abordado. Mora perto da escola. Foram alguns minutos entre a ligação com o réu e o momento que o viu sendo abordado. Foi menos de 10 minutos. Quando chegou na rua de cima o réu já estava sendo abordado. As perguntas do juízo disse que não tem conhecimento de desentendimento do réu e dos policiais arrolados como testemunhas. Que não conhece o adolescente Kauan e não conseguiu ver se ele também estava na esquina. Examinando o arcabouço probatório emergentes dos autos, nota-se a cabal comprovação de perpetração do crime de tráfico de entorpecentes. Ora, é inequívoco que o acusado trazia consigo e guardava substâncias entorpecentes,

conforme: 1) os coerentes e insuspeitos depoimentos dos Agentes Públicos, que narraram verossimilmente, a apreensão das drogas onde o acusado as dispensou; e 2) o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 97/100), o qual atestou que a substância apreendida era entorpecente. Igualmente indisfarçável é a finalidade

mercantil da droga, a despeito da não flagrância de ato de mercancia de narcóticos. Deveras, a infração penal de tráfico de entorpecentes é crime de ação múltipla e conteúdo variado, bastando, portanto, que o agente pratique qualquer um dos verbos nucleares contidos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com a intenção de traficar entorpecentes, para que o delito previsto no dispositivo legal retro mencionado reste configurado. Estabelecida esta premissa e escorada na previsão legal contemplada no § 2º, do art. 28, da Lei nº 11.343/06, verifico que as circunstâncias fáticas estão a evidenciar o dolo do réu de traficar a droga apreendida. Com efeito, tem-se: 1) a quantidade de narcóticos apreendidos; 2) sua forma de embalagem, em pequenas frações, forma de acondicionamento própria para a venda “a varejo” de entorpecentes; 3) a conduta do acusado, o qual, ao avistar a viatura, apresentou comportamento suspeito, consistente em dispensar drogas e tentar fugir; 4) a não apreensão de qualquer instrumento ou apetrecho utilizado para o consumo das drogas; 5) a localização do acusado em local notoriamente conhecido pelo comércio de drogas; e 6) a existência de fotografias, no aparelho celular apreendido, relativas a drogas. Válido mencionar que as fundamentações acima expostas foram utilizadas no precioso voto da lavra do Des. Rel. Penteado Navarro nos autos da Apelação 0005659-54.2010.8.26.0320, TJSP, 9ª Câmara de Direito Criminal, d.j. 24/11/2011, r. 28/11/2011, o qual transcrevo em parte: “Outrossim, havendo conhecimento de que o local onde os apelantes se encontravam era “ponto de tráfico” e, ainda, levando-se em consideração a quantidade da droga apreendida (8,9 g de “cocaína” em pedra e 3,2 g em pó), bem como a sua forma de acondicionamento (27 invólucros de plástico contendo pedrinhas de cor amarela, envoltos por plástico, sendo 4 na cor azul e 23 na cor branca, além de outros 27 invólucros da mesma substância e 11 invólucros tipo “ependorf” de plástico incolor com tampa, contendo pó de cor amarela - fls. 76/79), não resta qualquer dúvida de que os apelantes praticavam o comércio de drogas no local. Note-se que uma das principais circunstâncias indicadoras de tráfico é a quantidade de tóxico. E, para mim, tal mensuração deve partir da overdose (dose insuportável ou excessiva para alguém). Segundo a literatura médica, a reação letal ou não letal da “cocaína” em usuários depende de variados aspectos. Doses consideradas pequenas, cerca de 0,02g, podem ser suficientes para esse efeito (cf. Delton Croce e Delton Croce Júnior, Manual de Medicina Legal, 5ª ed., Saraiva, 2004, pág. 636). Logo, apreendidas 3,2 gramas da droga em pó, teremos cerca de 160 doses letais (excessivas ou insuportáveis) ao usuário. Até porque o uso continuado de “cocaína” provoca o “enfraquecimento das funções psíquicas em geral, cansaço, irritabilidade, inquietação e insatisfação” (cf. Edevaldo Alves da Silva, Tóxicos, 1ª ed., Bushatsky, 1979, pág. 82). Destarte, a conduta inserida em qualquer dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei de Drogas, implica em tráfico, onde o dolo é sempre genérico. Daí segue não ser indispensável para o caso a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga ou de associação para tanto, bastando o conjunto de indícios e presunções (circunstâncias ligadas ao fato probando) que envolve o agente acusado. Sem dúvida, o juiz não pode desprezar as regras de experiência comum (praesumptiones hominis), ou seja, a ordem normal das coisas. A experiência comum é aquele conhecimento adquirido pela prática e pela observação do cotidiano. Nesse sentido há manifestações da doutrina e da jurisprudência (cf. José Frederico Marques, Elementos de Direito Processual Penal, 1ª ed., Bookseller, 1997, vol. II, § 95, item 525, pág. 346, nota 9; Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., 2011, art. 239, item 4, págs. 544-5; Guilherme Madeira Dezem, Da Prova Penal, 1ª ed., Millennium, 2008, cap. IV, item, 12.2, págs. 272; STF, 2ª T., HC 70.344/RJ, rel. Min. Paulo Brossard, RTJ, 149/521; STJ, 6ª T., HC 15.736/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU, 23/04/01, pág. 189; LexSTF, 182/356; RT, 673/357, 711/378, 728/543, 744/602, 748/599, 758/583, 769/602 e 854/654; RJDTCrimSP, 5/167, 6/137, 7/105, 16/133, 25/324 e 28/209). Para Fernando de Almeida Pedroso, “em sede de tráfico de substância entorpecente, constituem prova indiciária do malsinado e vil comércio, exemplificativamente, a quantidade apreendida de estupefacientes, denotando sua incompatibilidade com a destinação para o próprio uso; a forma de fragmentação e acondicionamento do tóxico, confeccionado em diversas embalagens ou unidades distintas e individuais, indicando

o propósito de venda a varejo" (cf. Prova Penal, 2ª ed., RT, 2004, item 5, pág. 96) Nessa linha de entendimento, é a jurisprudência atualmente majoritária (cf., verbi gratia, RTJ, 149/521; RSTJ, 142/454 e 169/499; RJTJERGS, 177/57; LexJTJ, 165/334, 170/288, 174/333, 180/284, 186/305, 205/314, 208/272 e 277/523; RT, 537/335, 675/406, 714/357, 718/394, 727/478, 729/542, 737/684, 739/639, 740/634, 747/642, 776/663, 779/554, 789/536, 793/576, 793/727, 800/597, 801/606, 807/597, 832/588. Portanto, provado que se faz presente a elementar do tipo substância entorpecente (laudo de exame químico-toxicológico a fls. 97/100) e demonstrado que o réu incorreu em verbo nuclear contido no artigo 33, caput, da Lei 11343/06 - trazer consigo-, fazendo-o com a inegável e nítida intenção de traficar drogas (elemento subjetivo do tipo), resta caracterizada a infração penal indicada no dispositivo legal retro mencionado. Certo, portanto, que o réu perpetró o crime de tráfico de entorpecentes, não incorrendo em hipóteses de exclusão da ilicitude e/ou da culpabilidade, emerge-se o jus puniendi, razão pela qual passo a dosimetria da pena a ser lhe imposta. Observando as circunstâncias do artigo 59, caput, do Código Penal, verifico que as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao réu, na medida em que se cuida de réu reincidente. No entanto, como tal circunstância será apreciada em segunda fase, por ora, fixo sua pena-base no mínimo legal, isso é, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Em segunda fase, presente a agravante de reincidência, que, aliás, é específica (Proc. nº 0001097-78.2017.8.26.0571, fls. 30/31), agravo sua pena na fração de 1/5, gerando a reprimenda legal de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa. Cabe ressaltar a inaplicabilidade da agravante do estado de calamidade pública. Ora, não há provas de que o acusado se valeu das fragilidades proporcionadas pela situação calamitosa ou que agravou esse estado. Assim, imperioso o afastamento da agravante postulada pelo Parquet. Aliás, assim se posiciona a jurisprudência: "Contudo, entendo que a agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, relativa ao estado de calamidade pública, deve ter na sua incidência relação com o contexto do delito e a desproteção do bem jurídico tutelado pelo tipo penal. No entanto, no caso em apreço, entendo não comprovada relação direta entre o cometimento do delito e a emergência de saúde pública relacionada ao coronavírus (declarada pelo Decreto Legislativo nº 6, de 2020), de modo que o reconhecimento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, em razão do crime ter sido praticado durante estado de calamidade pública, deve ser afastado. Note-se que não há qualquer evidência nos autos de que o estado de calamidade tenha facilitado a ação criminosa, de que o apelante tenha se aproveitado dessa situação excepcional para perpetrar o delito ou, ainda, de que o crime tenha sido mais grave por ter ocorrido durante a pandemia" (TJSP; Apelação Criminal 1501673-18.2020.8.26.0530; Relator (a): Osni Pereira; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Preto - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/05/2021; Data de Registro: 31/05/2021). Finalmente, considerando que o crime foi praticado com o envolvimento adolescente, tem-se por necessária a incidência da causa de aumento de que trata o art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas. E, portanto, aumento sua pena em 1/6, gerando a reprimenda legal de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, a qual torno definitiva, à minguia de demais causas modificadoras da pena. A causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 é inaplicável ao caso sub judice. De fato, a incidência dessa benesse legal reclama a presença simultânea de 04 requisitos subjetivos, a saber, primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades delitivas e não integração a organização criminosa. In casu, tratando-se de réu reincidente, resta inviabilizada a concessão da benesse em questão. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal e, com fulcro no artigo 33, § 3º, c.c. art. 59, III, ambos do Código Penal, determino que o regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, dada a reincidência, que, aliás, é específica, do acusado, que reclama a fixação de regime prisional mais severo para a contenção do ímpeto criminoso do réu. As mesmas motivações acima expostas impedem a concessão dos benefícios do art. 44 do Código Penal. Por derradeiro, deixo de aplicar a regra da progressão antecipada (art. 387, §2º, do CPP), posto que a concessão desta medida dependa da análise de condições não exclusivamente objetivas, tal como o bom comportamento carcerário. Em assim

sendo, não havendo nos autos informações sobre o cumprimento da pena, a viabilidade de concessão desta benesse restou prejudicada. Neste diapasão é o entendimento do E. TJSP. Vejamos: "No que diz respeito à pretendida aplicação da Lei nº 12.736, tal pleito não pode ser atendido, pois a colenda Turma julgadora não possui elementos para fazê-lo, eis que não há informações a respeito do cumprimento da pena". (TJSP, 16ª Câmara Criminal, Apelação n. 0016604-05.2011.8.26.0114, Rel. Des. ALBERTO MARIZ DE OLIVEIRA, julgado em 04.06.2013). Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva para: 1) afastando a causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei de Drogas, condenar o réu JONATAS PEREIRA DE SOUZA, devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, c.c. art. 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 700 (setecentos) dias-multa, com valor unitário no mínimo legal; e 2) absolver o acusado da imputação de prática do crime previsto no art. 35, caput, da Lei 11.343/06, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Indefiro o Apelo em Liberdade ao réu, na medida em que permanecem inalteradas as razões que determinaram a segregação cautelar do acusado. E mais, considerando a reincidência, que aliás é específica, do acusado, evidente que, acaso solto, tornará a delinquir, motivo pelo qual sua prisão preventiva é absolutamente necessária para garantir a ordem pública. E não se venha alegar a situação de calamidade pública decorrente da doença COVID 19, gerada pela infecção do vírus sars-cov-2 ("coronavírus"). Trata-se de tema que reclama prudência judicial no exame das medidas cautelares pessoais, em especial, as prisões preventivas e temporárias. Isso porque, se é fato que as aglomerações de pessoas podem acelerar o contágio da doença e sua disseminação, também é verdade que a libertação indiscriminada dos presos, além de implicar indiscutível prejuízo à manutenção da segurança pública e da aplicação da lei penal (já que há o indiscutível risco de, em tese, praticar novos delitos ou por-se em fuga), também poderá propiciar, por esse fluxo acentuado de pessoas, maior transmissão da enfermidade. É dizer, pode ser que o preso, agora libertado, já esteja infectado, mas em quadro assintomático (o que, segundo dados científicos, pode demorar até 2 semanas ou nem mesmo se manifestar), o que proporcionará a infecção de seus familiares e outras pessoas com quem tiver contato. Outrossim, em estabelecimentos prisionais, onde o acesso de pessoas é controlado e, por ora, proibido, há menor probabilidade ser contaminado do que, em liberdade, saindo as ruas, onde não se tem controle sob a mobilidade dos cidadãos. Dito de outro modo, se a intenção é preservar a saúde do preso, é possível que, em liberdade, por não haver restrição e/ou controle de sua mobilidade, tenha maior possibilidade de contrair a doença do que preso, onde o acesso de pessoas é restrito e, por ora, proibido. O que se quer dizer, em síntese, é que a alegação de pandemia não conduz, invariavelmente, a soltura do preso. Devem ser analisadas outras peculiaridades do caso concreto. In casu, os elementos acima apontados denotam que é o caso de manutenção da prisão preventiva, o que não se altera com a situação de calamidade pública gerada pelo coronavírus. Até porque não se tem notícia de preso infectado na unidade prisional do acusado, que esse se encontra enfermo, tampouco que integra grupo de risco. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra recolhido. Oportunamente, expeça-se guia de recolhimento e arquivem-se os autos. Diante da condenação, fica ainda obrigado o réu a recolher custas de 100 (cem) UFESP's, na forma do art. 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03. Não lhe concedi os benefícios da Justiça Gratuita, pois o réu constituiu advogado (fls. 165), signo presuntivo de riqueza que revela a capacidade dele para suportar o ônus financeiro das custas processuais. Nos termos do Provimento da CG nº 11/2015, com o trânsito em julgado, calcule-se o valor referente às custas processuais e o total de pena de multa. Após, intime-se o réu para que efetue o pagamento no prazo de 10 (dez) dias. Sem prejuízo, considerando que o entorpecente apreendido já foi periciado, destrua-se a droga na forma da lei. Quanto aos demais bens apreendidos, acaso transitado em julgado e decorrido o prazo de 90 dias sem que se reclame a liberação dos demais objetos, destrua-se esses na forma do que preceitua os arts. 123 e 124, ambos do CPP. Pelo Defensor do réu e pelo réu foi manifestado o interesse em interpor

recurso. Pela MM. Juíza de Direito foi dito: Considerando que o Patrono do réu manifestou que deseja arrazoar na superior instância, nos termos do artigo 600, § 4º, do Código de Processo Penal, remetam-se os autos ao Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo". Com o trânsito em julgado da condenação criminal, lance-se o nome do réu no rol dos culpados. Oportunamente, arquivem-se os autos. Publicada esta em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. ENCERRADOS OS TRABALHOS, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pela MM. Juíza, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça. NADA MAIS. Eu, Mario Henrique Machado, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA